SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1091524 - SP (2026/0157231-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	ENIO BASTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TEMA 506/STF. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o *habeas corpus* impetrado de condenação transitada em julgado. Agravante condenado definitivamente pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.

2. Fato relevante. A Defesa pleiteia: (i) absolvição à luz do Tema 506/STF, diante da apreensão de 11,2 g de cannabis; (ii) reconhecimento de insuficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação; e, subsidiariamente, (iii) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com redução de 2/3, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

3. As decisões anteriores. A Corte local julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação por tráfico com base em conjunto probatório robusto (confissão detalhada na fase policial, relatos policiais, autos de flagrante, exibição e apreensão, laudo toxicológico e mensagens de WhatsApp pretéritas alusivas à traficância). Afastou o tráfico privilegiado em razão de dedicação a atividades criminosas e fixou o regime inicial fechado com fundamento na habitualidade delitiva.

Documento eletrônico VDA58879262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:41:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:18:57
Código de Controle do Documento: 647f74c7-4404-4e64-8c78-a3edde9e0b9a

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, à luz do Tema 506/STF e da quantidade apreendida, é possível desclassificar a condenação para conduta de usuário e absolver o Agravante; (ii) saber se há suporte probatório suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; (iii) saber se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (iv) saber se o regime prisional pode ser abrandado para o semiaberto, consideradas a pena de 5 anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é conhecido na ausência de manifesta ilegalidade no ato impugnado.

6. A desclassificação para uso próprio é inviável, pois o acervo probatório é robusto e coeso, composto por confissão detalhada na fase policial, depoimentos policiais firmes, autos de flagrante e de apreensão, laudo toxicológico e mensagens pretéritas de WhatsApp alusivas à traficância, suficientes para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

7. A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório quando ausente contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (CPP, art. 621, I).

8. O redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) permanece afastado, diante de elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e habitualidade delitiva, reveladas por mensagens pretéritas e demais dados dos autos.

9. O regime inicial fechado é inadequado no caso, devendo ser fixado o semiaberto, pois a pena definitiva é de 5 anos de reclusão, o Agravante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis, impondo-se observância ao art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal e exigindo fundamentação concreta para agravar o regime.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo parcialmente provido para estabelecer o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena reclusiva, mantidas a condenação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a negativa do redutor do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento:

---

1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio somente é conhecido diante de manifesta ilegalidade no ato impugnado. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, ausente afronta ao texto da lei penal ou à evidência dos autos. 3. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Com pena definitiva de 5 anos, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto é o adequado, sendo vedada a fixação de regime mais gravoso sem fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei n. 11.343/2006, art. 42; CP, art. 33, § 2º, "b", e § 3º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA58879262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:41:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:18:57
Código de Controle do Documento: 647f74c7-4404-4e64-8c78-a3edde9e0b9a

Trata-se de agravo regimental agravo interposto por **ENIO BASTOS DA SILVA** contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o *habeas corpus*, por tê-lo sido manejado como substitutivo de recurso próprio (e-STJ, fls. 46-47).

Segundo se infere dos autos, o agravante foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 dias-multa como incurso no art. 33, *caput,* da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões, a defesa reafirma: a) ser devida a absolvição do agravante, condenado por tráfico pela apreensão de 11,2 g de maconha, à luz da tese firmada no RE 635.659/SP (Tema 506, Supremo), segundo a qual "não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa" e, ainda, que "será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxe consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmea" (e-STJ, fls. 48-50); b) os depoimentos policiais isolados não são suficientes para sustentar a condenação; d) subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por inexistirem elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa nas mensagens extraídas do celular (e-STJ, fls. 52-53); g) a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal e do precedente HC 596.603/SP (e-STJ, fls. 54).

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para: i) absolver o agravante nos termos do art. 386, III, do CPP, à luz do Tema 506 do Supremo (e-STJ, fls. 48-51); ou, subsidiariamente, ii) aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com redução máxima de 2/3, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos (e-STJ, fls. 52-54).

É o relatório.

VOTO

O agravo merece parcial provimento.

Preliminarmente, vale anotar que o *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio será conhecido apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade verificada no ato impugnado, **o que não é a hipótese dos autos.**

A Corte local julgou improcedente a revisão criminal no qual se buscava a desclassificação da condenação do ora agravante para conduta de mero usuário, sob o entendimento de que não haveria contrariedade ao decido no Tema 506/STF pois robusto o conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA58879262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:41:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:18:57
Código de Controle do Documento: 647f74c7-4404-4e64-8c78-a3edde9e0b9a

> No caso, a manutenção da condenação por tráfico é medida de rigor.
> Nesse sentido, a detalhada confissão do revisionando na fase policial, bem como e, sobretudo, os seguros e convincentes informes prestados pelos policiais, os quais, acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar (fl. 11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/106), relatório policial (fls. 109/111), bem assim do relatório sobre a troca de mensagens de WhatsApp encontradas no celular do requerente, alusivas ao tráfico de entorpecentes em ocasiões pretéritas (fls. 140/149), servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
> Registre-se que os policiais militares Reinaldo Pinto da Fonseca e Jorge Fernando Soares deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas envolvendo o ora peticionário. Em síntese, em depoimentos coerentes e harmônicos, os policiais disseram que receberam denúncia anônima, fornecendo características pessoais de dois indivíduos que estariam exercendo tráfico de drogas no Posto Chicago. Lá chegando, visualizaram o revisionando e o corréu Geovan, momento em que o revisionando dispensou 06 trouxinhas de entorpecente no chão e, durante a abordagem, com o corréu foi apreendida certa quantidade de entorpecente. Declararam que no Posto Chicago chegavam vários ônibus conduzindo presos em gozo de saída temporária, os quais se aproximavam do revisionando e do corréu, momento em que era feita a negociação das drogas (fls. 02/03 e 04 e mídia).
> [...]
> Na espécie, embora a quantidade de substância entorpecente apreendida seja inferior aos 40g fixados pelo STF, as circunstâncias da prisão em flagrante não deixam dúvidas de que não se destinava a consumo próprio, mas, sim, ao tráfico ilícito.

Conforme se observa, a defesa não conseguiu comprovar que a condenação está em evidente desacordo com a prova dos autos ou em manifesta violação à norma penal. No ponto, vale ressaltar que é ônus do requerente demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o juízo condenatório afronta diretamente os elementos probatórios ou o ordenamento jurídico.

Verifica-se, desse modo, que a pretensão defensiva se resume à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido "do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).

Por sua vez, o tráfico privilegiado foi mantido afastado sob o entendimento de que "em sede de revisão criminal só é possível a redução da pena quando fruto de erro, quer em razão de operações aritméticas para o encontro de seu quantum final, quer pela afronta a texto legal em sua fundamentação" (e-STJ, fl. 26), sendo que, na espécie, está "presentes elementos concretos nos autos a demonstrar que o requerente exercia pelo menos desde o ano de 2021 o nefasto comércio de drogas (cf. relatório de mensagens extraída de celular fls. 140/149 da origem), evidenciando sua dedicação a atividades criminosas".

Documento eletrônico VDA58879262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:41:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:18:57
Código de Controle do Documento: 647f74c7-4404-4e64-8c78-a3edde9e0b9a

No ponto, vale anotar que esta Corte, inclusive em petição atravessada no AResp 2601030) pelo ora agravante, já se manifestou pela ausência de ilegalidade na negativa de aplicação do referido benefício legal, uma vez que há dados concretos que evidenciam a habitualidade delitiva do agente na traficância.

Por fim, o pedido de alteração do regime prisional merece acolhimento.

No caso, observa-se que o modo inicial fechado foi definido com base na gravidade abstrata do delito em confronto com a Súmula 440/STJ, assim com na verificação do envolvimento habitual do agravante na traficância, argumento este, todavia, já oportunamente utilizado para negar o privilégio especial da Lei de Drogas. Assim, aplicada a pena final em 5 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e primário o agravante, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
> I. Caso em exame
> 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve o regime inicial fechado para cumprimento de pena por associação para o tráfico de drogas, apesar de o réu ser primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal.
> 2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena do crime de associação para o tráfico de drogas para 4 anos e 1 mês de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.
> 3. A Defesa sustenta a ilegalidade do regime inicial fechado, argumentando que o paciente é primário e a pena imposta é inferior a oito anos, o que, segundo a legislação, determinaria o regime semiaberto.
> II. Questão em discussão
> 4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado é válida quando o réu é primário e a pena-base foi fixada no mínimo legal.
> III. Razões de decidir
> 5. A inexistência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, considerando que o réu é primário e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, configura ofensa às Súmulas n. 440 do STJ e n. 718 e 719 do STF.
> 6. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, somente é possível a fixação de regime mais gravoso quando demonstrada a existência de comportamento que denote gravidade excepcional.
> IV. Dispositivo e tese
> 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena.
> Tese de julgamento: "1. Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A fixação de regime mais gravoso exige fundamentação específica que considere circunstâncias judiciais desfavoráveis ou dados concretos que demonstrem gravidade excepcional."

Documento eletrônico VDA58879262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:41:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:18:57
Código de Controle do Documento: 647f74c7-4404-4e64-8c78-a3edde9e0b9a

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 33, § 2º, "c"; CPP, art. 654, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 809.793/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 713.364/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13.12.2022.
(HC n. 951.446/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, afastando o redutor do tráfico privilegiado, com base na dedicação do réu às atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e se o regime prisional pode ser abrandado para o semiaberto.
III. Razões de decidir
4. A expressiva quantidade de drogas e a apreensão de objetos relacionados ao tráfico indicam dedicação do réu às atividades criminosas, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
5. A modificação do regime prisional para o semiaberto é cabível, considerando a pena aplicada de 5 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva.
Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. O regime inicial semiaberto é cabível quando a pena aplicada é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, as circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu é primário".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;
Código Penal, art. 33, § 2º, "b".Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.141.983/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.814.944/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC 401.235/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 05.10.2017; STJ, HC 413.244/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.10.2017.
(AgRg no HC n. 988.096/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Diante do exposto, **dou parcial provimento** ao agravo regimental para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva.

É como voto.

Documento eletrônico VDA58879262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 00:41:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:18:57
Código de Controle do Documento: 647f74c7-4404-4e64-8c78-a3edde9e0b9a